

第17問

甲は、乙と口論中、乙が興奮して手を振り上げたのを自分になぐりかかってくるものと誤信し、その難を避けようとして、たまたま所持していた日本刀で乙を切りつけたところ、乙は出血多量のため、即死した。甲の罪責を論ぜよ。

(旧司法試験 昭和45年度 第1問)

第1 構成要件該当性

甲が日本刀で乙を切りつけ、即死させた行為は、殺人罪（199）の構成要件に該当する。

殺傷能力の高い日本刀を用いていることから、殺意も問題なく認められる。

第2 違法性

甲は、乙が殴りかかってくるものと誤信しているものの、そのような事実はないから、「急迫不正の侵害」（36Ⅰ）はなく、正当防衛は成立しない。

他に違法性阻却事由はない。

したがって、違法性も認められる。

第3 責任（**論点** 誤想（過剰）防衛 司H29,R4,予R2,旧H6-1,H9-1）

 91 頁  35 頁

- 1 もっとも、いわゆる誤想防衛が成立する余地があるため、これを検討する必要がある。

この点については、様々な学説が存在するところではあるが、通説は、行為者に過剰性を基礎付ける事実の認識がある場合は故意は阻却されず、他方、そのような事実認識のない場合は、（誤信に相当な理由があるか否かを問わず、）故意が阻却されとする事実の錯誤説に立つ。判例も同様の立場に立つのではないかという評価もある。

- 2 誤想防衛の成否を検討するに当たっては、行為者の認識した事情が、正当防衛の要件を満たすものであったかを検討すればよい。満たす場合には誤想防衛が成立する。

本問では、乙が殴りかかってくるものと誤信しているから「急迫不正の侵害」に対して「防衛」する認識はあるが、乙が素手で攻撃を加えようとしているのに対して、甲は日本刀を用いているから、「やむを得ずにした行為」（防衛行為の相当性）であるとの認識がない。

したがって、過剰防衛の認識下で行為しているから、誤想防衛が成立せず、故意も阻却しない。

- 3 なお、問題文の事実が明らかではないものの、甲は、乙と口論していることから、自招侵害や喧嘩闘争の問題を検討する余地もある（**論点** 相互闘争状況  司H18,H23,R4,予H26）。

 65 頁  19 頁

もっとも、本問では、正当防衛は成立せず、誤想（過剰）防衛の成否が問題となるに止まるから、典型的な自招侵害の問題とは異なる。

仮に、この点を検討するとした場合、「闘争の全般からみては、刑法第36条の正当防衛の観念を容れる余地がない場合」（最大判昭23.7.7）、「何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない」（最決平20.5.20【百選Ⅰ26】）場合には当たらないだろうから、この点が誤想防衛の成否に影響を与えることはないだろう。

第4 誤想過剰防衛の処理

以上より、甲には殺人罪が成立するが、過剰防衛の認識があるため（いわゆる誤想過剰防衛）、過剰防衛（36Ⅱ）の規定が準用されるかを

検討する。

この点についても、様々な学説が存在するところではあるが、例えば、過剰防衛の法的根拠について責任減少説をとる立場からは、誤想過剰防衛の場合にも責任が減少するとして準用が認められる、などと言われている。理論構成は明らかではないが、判例（最決昭41.7.7、最決昭62.3.26【百選 I 29】）も同じ結論をとる。

なお、学説上は、刑の免除の規定の準用は認めないとする立場もある。

答案構成

第1 構成要件該当性

殺人罪（199）の構成要件に該当する

第2 違法性

正当防衛（36 I）その他の違法性阻却事由なし

第3 責任

1 違法性阻却事由に錯誤があるとして、故意を阻却しないか

↓

事実の錯誤説

↓

2 甲の認識を基準として、正当防衛の要件検討

↓

「やむを得ずにした行為」（防衛行為の相当性）が否定され、正当防衛不成立

↓

過剰防衛の認識に止まり、故意阻却なし

↓

他の責任阻却事由もなし

↓

殺人罪成立

第4 誤想過剰防衛の処理

過剰防衛についての責任減少説

↓

36条2項準用（ただし、免除の規定は準用なし）

第1 構成要件該当性

甲が、日本刀で乙を切りつけ、即死させた行為は、「人を殺した」ものとして、殺人罪（199条）の構成要件に該当する。また、殺傷能力の高い日本刀を用いていることからすれば、殺意（38条1項）を肯定することができる。

第2 違法性

甲は、乙が殴りかかってくるものと思って上記行為に及んでいるものの、そのような事実はないため、「急迫不正の侵害」（36条1項）は認められない。そのため、正当防衛は成立しない。

また、他に違法性阻却事由はない。

したがって、違法性も認められる。

第3 責任

1 もっとも、甲は、乙が殴りかかってくるものと誤信し、上記行為に及んでいる。甲の認識を基準とすれば、正当防衛が成立する余地がある。このように、行為者が、違法性阻却事由がないのにあると考えている場合、故意（38条1項）があるといえるか。

故意責任の本質は犯罪事実の認識によって反対動機が形成されるのに、あえて犯行に及んだ点に求められるから、自己の犯罪事実を認識・認容した場合、故意責任を問うことができると解する。

ここで、犯罪事実とは、構成要件に該当する違法な行為であるから、違法性阻却事由がないのにあると認識した場合、犯罪事実を認識・認容しているとはいえない。

1

したがって、違法性阻却事由に錯誤ある場合、犯罪事実を認識・認容しているとはいえず、故意は阻却される。

2 そこで、甲の認識を基準として正当防衛の成否を検討する。

(1) まず、甲は上記行為に及ぶ前に乙と口論をしており、真実乙が甲に対して暴行を加えようとしたのであれば、いわゆる自招侵害行為と見る余地がある。自招侵害行為については、何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない場合には、正対不正の関係ともいべき正当防衛を基礎付ける前提を基本的に欠いた、不正対不正の状況にほかならず、およそ正当防衛の成立が否定される。

本問では、仮に、甲及び乙の両名が、口論をしていただけであるにもかかわらず、いきなり乙が殴りかかってきたのであれば、甲に何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない場合には当たらない。

したがって、およそ正当防衛の成立が否定されるわけではない。

(2) 改めて正当防衛の要件について検討すると、本問では、乙が殴りかかってくるものと誤信し、その難を避けようとして上記行為に及んでいるから、「急迫不正の侵害に対して、自己……の権利を防衛する」認識はある。

もっとも、「やむを得ずにした行為」とは、防衛手段の相当性をいうところ、乙が素手で攻撃を加えようとしているのに対して、甲は、日本刀を用いているから、防衛手段の相当性を欠いており、「やむを得ずにした行為」であるとの認識がない。

2

したがって、甲の認識を基準とすると、過剰防衛が成立するにとどまるから、正当防衛の事実を認識しているとはいえ、違法性阻却事由の錯誤として、故意を阻却しない。

他に責任阻却事由も認められないから、甲に殺人罪が成立する。

第4 誤想過剰防衛の処理

ただし、上記のように、甲には、過剰防衛の認識があるから、いわゆる誤想過剰防衛の問題となる。

過剰防衛については、急迫不正の侵害を認識している以上、行きすぎがあっても非難できない面があることからすれば、過剰防衛による刑の任意的減免の根拠は、たとえ過剰なものであっても行為者を非難し得ないとの責任減少を求めることができる。

過剰性の認識がある場合も、同様に責任減少が認められる以上、過剰防衛の規定（36条2項）を準用するべきである。とはいえ、免除の規定を準用することは許されない。過剰性に認識がない場合も、過失犯が成立し、刑が科される可能性がある一方で、故意犯が成立するのに刑が全部免除されるというのは結論として不均衡だからである。

以上